

1506741-85.2021.8.26.0344

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Josiane Patricia Cabrini Martins Machado

Comarca: Marília

Foro: Foro de Marília

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/01/2022

... Lei nº 11.343/06, de que o réu praticava o tráfico ilícito de entorpecentes, não se tratando, pois, de mero usuário.

Ressalte-se que o possível uso de drogas não elimina a incidência do crime mais grave. Pelo contrário. O crime mais brando fica absorvido pelo tráfico. Ou seja, eventual condição de usuário não exclui a de traficante: "Oportuno dizer que a condição de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Marília

Foro de Marília

1ª Vara Criminal

Rua Lourival Freire, 120, Marília - SP - cep 17519-050

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1506741-85.2021.8.26.0344 - lauda

CONCLUSÃO

Em 18 de janeiro de 2022, faço os autos conclusos à MM. Juíza de Direito, Dra. Josiane Patricia Cabrini Martins Machado. Eu, Juliana Baccelli Fernandes Cunha, M364719, subscrevi.

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1506741-85.2021.8.26.0344 - Controle 2021/001361

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALISSON APARECIDO DE SA GOMES

Vistos.

ALISSON APARECIDO DE SÁ GOMES (RG: 46.528.079, filho de Nilson Aparecido Gomes e Lucineia de Sá Gomes) foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, no dia 21 de julho de 2021, por volta das 15h, na Avenida Antônio Lourenço, nº 250, nesta cidade e Comarca de Marília/SP, mantinha em depósito, para entrega a consumo de terceiros, sem autorização legal e regulamentar, 112,97g (massa líquida) de cocaína e 63,21g (massa líquida) de Cannabis sativa L, vegetal conhecido por maconha, que possui tetrahydrocannabinol, substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica.

Recebida a denúncia (fls. 117/119), o réu foi citado (fls. 131) e apresentou resposta à acusação (fls. 135/146).

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas, sendo o acusado interrogado ao final.

Alegações das partes constantes do termo retro.

É o relatório. Fundamento e decido.

O pedido inicial é procedente.

A materialidade e a autoria delitivas foram demonstradas pelo boletim de ocorrência (fls. 12/14), auto de exibição e apreensão (fls. 15/16), fotografias (fls. 19/21), laudo de constatação (fls. 22/24), laudo definitivo (fls. 96/100) e pela prova oral colhida.

Os policiais civis Marli e William declararam, na fase inquisitiva, que, na data dos fatos, no período da tarde, por volta das 15h, em companhia de outros policiais, visando combater o tráfico de entorpecentes na Avenida Antônio Lourenço, avistaram, em uma viela localizada ao lado do número 250, três indivíduos em atitude suspeita, cerca de 10 (dez) metros da mencionada via pública, tudo indicando que estavam praticando a venda de drogas. Com a intenção de observá-los, estacionaram a viatura nas proximidades, sendo que, logo em seguida, um veículo branco estacionou no local e o réu foi até o condutor, recebendo, aparentemente, dinheiro; ato contínuo, se deslocou até os outros dois indivíduos, pegou algo e entregou ao motorista do veículo, o qual saiu rapidamente do local. Diante dos fatos, tendo a certeza de que estava ocorrendo o tráfico no local, procederam à abordagem, momento em que o acusado, percebendo a ação policial, gritou "olha o bicho" e todos correram em direção à viela, sendo possível apenas a detenção do réu. No local em que foi visto pegando algo para entregar ao condutor do veículo encontraram um saco plástico com 4 (quatro) "mucas", uma delas com 182 (cento e oitenta e dois) pinos de cocaína na cor amarela, bem como a quantia de R\$ 76,65 (setenta e seis reais e sessenta e cinco centavos); uma com 57 (cinquenta e sete) pinos de cocaína na cor verde; outra com 77 (setenta e sete) pinos de crack na cor escura; e uma com 20 (vinte) porções de maconha tipo "bananinha". Em juízo, acrescentaram que o local já era bastante conhecido como ponto de venda de drogas, motivo pelo qual realizaram breve campanha (cerca de 15 a 20 minutos) visando ao êxito da diligência. Ainda, relataram que um dos indivíduos que estavam com o acusado deixou uma sacola cair durante a fuga, sendo que, dentro desta, foram apreendidos drogas e dinheiro. Ao ser abordado, o réu, que não era conhecido pelos investigadores, afirmou ao eles que estava na função de olheiro e que realmente pegou dinheiro do condutor do veículo e depois entregou a ele a droga que obteve com um dos traficantes que ali estava, sendo que era essa sua função. Ainda, esclareceu que fazia esse tipo de serviço na "biqueira", ganhando R\$ 80,00 (oitenta reais) em dias de semana e R\$ 100,00 (cem reais) aos finais de semana. O acusado, por sua vez, na delegacia, afirmou que não estava vendendo drogas no local, mas em "serviço de campanha", sendo que a venda era realizada por "Nuno" e "Rafael", cujos endereços não soube informar. Relatou que, ao notar a aproximação dos policiais, chegou mesmo a gritar: "olha o bicho", expressão utilizada para avisar sobre a aproximação da polícia nas "biqueiras". Contudo, declarou que nunca vendeu drogas, sendo que foi internado na "Fundação Casa" uma única vez em razão da quebra de liberdade assistida, ficando no local por cerca de três meses. Esclareceu que ganhava a importância de R\$80,00 (oitenta reais) por dia para fazer campanha no local, sendo que permanecia das 8 às 22h, de segunda a quinta feira, além de R\$100,00 (cem reais) para ficar de sexta a domingo, das 8 às 2h do dia seguinte; fazia isso há mais de um mês por estar desempregado. Ademais, esclareceu que, além da campanha, era responsável pelo atendimento dos clientes que chegavam ao local de carro, recebendo deles o dinheiro e posteriormente entregava a droga que pegava com os outros dois indivíduos. Por fim, relatou que normalmente a "biqueira" vende R\$9.000,00 (nove mil reais) por dia e o dinheiro arrecadado é normalmente enterrado nas imediações pelas pessoas que recolhem (Danilo, vulgo "Bode", e Felipe, vulgo "Lipec"), em local que não soube informar. Em seu interrogatório judicial, confirmou a versão dos policiais de que recebeu o dinheiro do condutor do veículo e lhe entregou a droga solicitada. Também, confirmou que recebia dinheiro para auxiliar na venda de drogas, gastando tudo que recebia para sustentar seu vício (em crack e cocaína). Todavia, esclareceu que sua função não era vender a droga, mas sim entregá-la ao consumidor e alertar sobre eventual aproximação policial. Disse que uns policiais o abordaram e outros perseguiram os outros dois que ali estavam ("Nuno" e "Rafael"), sendo que um deles deixou uma sacola com drogas cair, a qual foi apreendida. Afirmou que não conhecia os policiais que o abordaram. Ainda, a

despeito de fazer uso de muito droga (cerca de 16 - dezesseis - pinos por dia) e não ter passado por tratamento para drogadição, deixou de usar entorpecentes desde que preso.

Ora, da prova produzida, verifica-se que ela é conclusiva e indica, com segurança, a traficância exercida pelo réu.

Primeiro, oportuno advertir que os policiais, sejam civis ou militares, são agentes públicos que gozam de presunção de legitimidade no exercício da função, de modo que seus depoimentos devem ser acolhidos, pois não se vislumbram elementos que indiquem que pretendiam, na verdade, prejudicar pessoa inocente, contra quem não nutrem inimizade ou hostilidade, relatando fatos inverídicos e “plantando” provas.

Neste sentido, por analogia: “Aliás, imperioso esclarecer que o policial militar não está impedido de depor, merecendo o seu testemunho a mesma credibilidade que é dada a qualquer pessoa, sendo que o depoimento policial só deve ser desconsiderado, quando exista uma razão clara e concreta para tornar referido depoimento eivado de suspeição. A este argumento acrescenta-se que os Tribunais Superiores já se pronunciaram no sentido que é idônea a prova testemunhal colhida no auto de prisão em flagrante e reafirmada em Juízo, com plena observância do contraditório, mesmo que constituída apenas por depoimentos de policiais que realizaram o flagrante (STF: HC nº 77.565/SP, DJ de 02/02/2001, Rel. Min. Néri da Silveira, HC nº 76557, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 04/08/98; e STJ: HC nº 30.776/RJ, DJ de 08/03/2004, Rel.^a Min. Laurita Vaz).” (Apelação nº 0007467-17.2016.8.26.0019, 12ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Des. Álvaro Castello, j. 28.6.2017). E ainda: “Vale destacar que os policiais são agentes públicos que gozam da presunção de idoneidade no exercício da função e, por isso, as suas declarações devem ser acolhidas sem reservas, especialmente senão se demonstrou interesse concreto da sua parte na incriminação do acusado. A respeito do assunto é iterativa a jurisprudência no sentido de que 'o depoimento de policial obedece aos mesmos princípios aplicáveis ao restante das pessoas, não havendo que se falar em suspeição ou inidoneidade considerando-se somente sua condição funcional' (RT 752/589).” (Apelação nº 0030961-20.2015.8.26.0576, 10ª Câmara Criminal Extraordinária do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Des. Tristão Ribeiro, j. 30.6.2017).

No caso dos autos, verifica-se que os depoimentos dos investigadores foram harmônicos, lógicos, coerentes e livres de dúvidas desde a fase inquisitiva, repetindo-se na judicial, nada indicando intenção deliberada de prejudicar o réu, que sequer conheciam, assim como o acusado também não conhecia os investigadores que o abordaram, conforme por ele mesmo afirmado. Não bastasse, houve a confissão integral do crime em juízo.

Quanto ao mérito propriamente dito, destaca-se que o acusado praticou conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei de Drogas, ou seja, mantinha em depósito, para entrega a consumo de terceiros, bem como, efetivamente, entregou a consumo, substâncias entorpecentes sem a devida autorização legal ou regulamentar.

Do exame dos autos, extrai-se que, durante diligências com a intenção de combater o tráfico de entorpecentes na Avenida Antônio Lourenço, os policiais civis avistaram três indivíduos em atitude suspeita em uma viela localizada ao lado do número 250, local conhecido como ponto de venda de drogas. Após breve campana, visualizaram o acusado atender o condutor de um veículo branco, recebendo algo (indicando tratar-se de dinheiro), que entregou a um dos outros dois indivíduos que ali estavam, bem como, em seguida, deu ao condutor o que pegou instantes antes, tudo indicando que estavam praticando a venda de drogas. Diante dos fatos, procederam à abordagem, momento em que o acusado, notando a ação policial, gritou “olha o bicho” e todos correram em direção à viela. Um dos indivíduos que estava com o acusado deixou uma sacola cair durante a fuga, sendo que, dentro desta, foram apreendidas drogas e dinheiro, a saber: 4 (quatro) “mucas”, uma delas contendo 182 (cento e oitenta e dois) pinos de cocaína na cor amarela, 57 (cinquenta e sete) pinos de cocaína, 77 (setenta e sete) pinos de crack e 20 (vinte) porções de maconha tipo “bananinha”, bem como a quantia de R\$76,65 (setenta e seis reais e sessenta e cinco centavos). Ao ser abordado, o acusado, que não era conhecido pelos investigadores, afirmou a eles que estava na função de olheiro e que realmente pegou o dinheiro do condutor

do veículo e depois entregou a ele a droga que obteve com um dos traficantes que ali estava, sendo que era essa sua função. Ainda, esclareceu que fazia esse tipo de serviço na "biqueira", ganhando R\$80,00 (oitenta reais) em dias de semana e R\$100,00 (cem reais) aos finais de semana.

De se destacar que a versão apresentada pelos investigadores foi confirmada pelo próprio acusado, que admitiu auxiliar traficantes, recebendo dinheiro em troca, o qual gastava com entorpecentes, eis que usuário. Ainda, admitiu que realmente recebeu dinheiro do condutor do veículo visto pelos investigadores, entregando a ele a droga solicitada.

Sobre o elemento subjetivo do tipo, consigna Andrey Borges de Mendonça e Paulo Roberto Galvão de Carvalho, na página 101 do livro "Lei de drogas comentada artigo por artigo" (3ª ed. São Paulo: Método, 2012): "O crime é essencialmente doloso. Não se exige qualquer elemento subjetivo específico, bastando a consciência e a vontade de realizar alguma das condutas descritas. Embora a expressão 'tráfico de drogas' esteja associada, na linguagem comum, à ideia de mercancia e lucro, o conceito jurídico é diverso, pois não se exige qualquer elemento subjetivo, além da simples consciência e vontade de praticar qualquer dos dezoito verbos-núcleos mencionados. O tipo, portanto, não exige qualquer elemento subjetivo específico, bastando o conhecido 'dolo genérico'".

No mais, a solução legal para se concluir pela distinção entre o simples usuário de entorpecentes e o traficante vem da análise dos elementos constantes do artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006. Com base no que está ali descrito é possível identificar em qual condição se encaixa o acusado.

Neste contexto, observo que a quantidade de entorpecentes apreendida (112,97g - massa líquida - de cocaína e 63,21g - massa líquida - de Cannabis sativa L - tudo dividido em mais de 330 - trezentas e trinta - porções individuais de droga), o alto poder vulnerante deles, além da forma de embalagem e as circunstâncias da prisão, que se deu em local conhecido pela venda de entorpecentes depois dos policiais avistarem o acusado vendendo drogas a uma pessoa que ali chegou de carro, sendo certo que ele tentou fugir da abordagem e ainda gritou "olha o bicho" para avisar comparsas da chegada dos investigadores, revelam que se trata o réu, de traficante. Não se olvide que tudo foi confirmado em juízo pelo próprio acusado.

Assim, considerando todos os elementos trazidos aos autos (quantidade de entorpecentes apreendida; natureza altamente vulnerante das drogas; acondicionamento típico para venda; quantia em dinheiro; local já conhecido como ponto de venda de drogas, além das circunstâncias em que flagrado: visto recebendo dinheiro e entregando drogas), convenço-me, indubitavelmente, nos termos do artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, de que o réu praticava o tráfico ilícito de entorpecentes, não se tratando, pois, de mero usuário.

Ressalte-se que o possível uso de drogas não elimina a incidência do crime mais grave. Pelo contrário. O crime mais brando fica absorvido pelo tráfico. Ou seja, eventual condição de usuário não exclui a de traficante: "Oportuno dizer que a condição de usuário não afasta, necessariamente, a de traficante, pois, como é sabido, na maioria das vezes, os usuários se valem do comércio ilícito de entorpecentes para sustentar o próprio vício, de modo que uma conduta não exclui a outra." (TJSP - Apel. 0006495-60.2008.8.26.0655; j. 11.4.2013).

Quanto às causas de aumento ou diminuição de pena, de se levar em conta que não incide o redutor previsto no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, pois a quantidade de entorpecentes e as circunstâncias da prisão, já examinadas, indicam o exercício constante de atividades ilícitas. De se notar que o próprio acusado admitiu que trabalhava na cadeia do tráfico, recebendo cerca de R\$ 80,00 a R\$ 100,00 por dia - a depender do dia da semana - para receber dinheiro dos usuários, entregar droga, bem como alertar sobre a chegada da polícia. Ora, evidnete que deve ser afastado o benefício em questão.

Portanto, caracterizado o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, provada a autoria e materialidade, e afastadas as teses defensivas por tudo que se expôs passo, com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, à fixação da pena. Atenta aos requisitos do artigo 42 da Lei 11.343/06 e artigo 59 do Código Penal, observo que a quantidade de droga apreendida com o réu, além do alto poder

vulnerante, autorizam a fixação da reprimenda em patamar superior ao mínimo, eis que demonstram o alto grau de periculosidade do agente e de reprovabilidade da conduta. Assim, estabeleço a pena em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, aumentando a pena mínima prevista no tipo em 1/6 (um sexto).

Na segunda fase, não há agravantes. Vislumbro a presença da atenuante da confissão, motivo pelo qual retorno a pena no mínimo: 5 (cinco) anos de reclusão.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e de diminuição.

A pena pecuniária é fixada em 500 (quinhentos) dias-multa, cada qual com valor unitário de um trigésimo do salário mínimo, reajustados a partir da data do fato, critério previsto no artigo 49, § 2º, do Código Penal.

Fixo o regime inicial fechado para cumprimento da pena privativa de liberdade imposta. Primeiro, porque o crime praticado pelo acusado é daqueles equiparados aos hediondos, sendo totalmente incompatível com o sistema mais rigoroso previsto na Lei 8.072/90 e na própria Lei Antitóxicos a concessão de quaisquer benefícios ou a fixação de cumprimento inicial de pena em regime mais brando. Ademais, de se levar em conta a gravidade da conduta praticada, já descrita anteriormente, bem como que as circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao réu.

Atenta ao teor da Lei 12.736/12, a detração de pena e a progressão de regime deverão ser oportunamente analisadas em sede de execução penal, no Juízo competente para tal, com base na guia de recolhimento, na folha de antecedentes e nas informações carcerárias do condenado, após a realização dos devidos cálculos. Como bem se sabe, a progressão não se dá automaticamente, dependendo do requisito subjetivo atestado pelo Diretor do estabelecimento em que se encontra o preso, de boa conduta carcerária, além do preenchimento do lapso temporal necessário.

Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE o pedido inicial para condenar ALISSON APARECIDO DE SÁ GOMES, qualificado nos autos, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal, por incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Nego ao réu o apelo em liberdade. A gravidade em concreto da conduta por ele praticada, já mencionada quando da decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva e nesta decisão confirmada, demonstra a necessidade de continuidade da custódia, haja vista que o próprio acusado admitiu fazer da prática do ilícito em comento seu meio de vida, sobretudo como forma de sustentar seu vício. A ordem pública, pois, deve ser preservada, evitando-se a reiteração da conduta, bem como se deve acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face do crime e de sua repercussão. Ademais, sabedor da condenação, pode buscar meios de eximir-se da aplicação da lei penal.

Assim, recomende-se o réu na prisão em que se encontra recolhido.

Declaro o perdimento, em favor da União, na forma do artigo 63 da Lei 11.343/06, do valor apreendido (R\$76,65 - setenta e seis reais e sessenta e cinco centavos), por ausência da comprovação da origem lícita do dinheiro (fls. 15). Oficie-se, oportunamente.

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao TRE, para atendimento do disposto no inciso III do artigo 15 da CF.

Custas na forma da Lei Estadual nº 11.608/03, observado o artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

Expeça-se o necessário para o cumprimento desta decisão.

P.I.C.

Marília, 31 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA